

1501797-09.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... de quitá-la, decidiu trabalhar para o tráfico a fim de saldar o débito. Afirmou que as drogas apreendidas estavam sob sua guarda e se destinavam ao tráfico. Informou que a quantia apreendida em seu poder era produto da venda de drogas daquele dia.

Em juízo, afirmou que é dependente de "crack" há 22 anos e foi até o local para comprar drogas. Nunca teve passagem por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501797-09.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501797-09.2022.8.26.0537 Controle nº 1349/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALTER PALMA REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

WÁLTER PALMA REIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 do Código Penal, porque no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 12:40 horas, no escadão que dá acesso à Passagem do Infinito, altura do n.º 10, Bairro Jardim Inamar, adquiriu, guardava, tinha em depósito, entregou e forneceu, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 59/61).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 99/100), sendo a denúncia recebida em 25.10.22 (fls. 106). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem

provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela reincidência, que seja afastada a redução do art. 33, §4.º e fixação de regime fechado.

O Dr. Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação que seja compensada a atenuante da confissão extrajudicial com a reincidência, a detração penal e regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 06), o réu confessou a prática do crime. Disse que é usuário de drogas. Falou que possuía uma dívida de R\$ 800,00, referente à aquisição de drogas, e que, por não ter condições financeiras de quitá-la, decidiu trabalhar para o tráfico a fim de saldar o débito. Afirmou que as drogas apreendidas estavam sob sua guarda e se destinavam ao tráfico. Informou que a quantia apreendida em seu poder era produto da venda de drogas daquele dia.

Em juízo, afirmou que é dependente de "crack" há 22 anos e foi até o local para comprar drogas. Nunca teve passagem por tráfico e os policiais tem que levar alguém. Trabalhava como serralheiro. Tem condenação por roubo estava em R.A. Não conhecia os policiais.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 04/05), relataram que diligenciaram até a Rua Imbaúva, conhecido ponto de tráfico de drogas, em uma viatura descaracterizada, e realizaram breve "campana". Narraram que viram o réu e outro homem no "escadão" da Passagem do Infinito, que dá acesso à Rua Imbaúva. Disseram que presenciaram o réu (cor branca, trajando calça jeans e camiseta branca), receber uma cédula de dinheiro do outro homem (provavelmente um usuário de drogas), ir até uma caixa de papelão, apanhar algo e entregar para aquele. Então, abordaram o réu e localizaram a quantia de R\$ 91,00 no bolso da calça dele. Afirmaram que o réu falou que era usuário de drogas, mas depois indicou que havia drogas para venda em uma caixa de papelão, localizada no solo, que servia como lixeira. Informaram que em buscas na baixa de papelão localizaram uma sacola plástica contendo 26 invólucros de cocaína, 10 pedras de "crack" e 5 porções de maconha.

Álvaro (policial), em juízo, afirmou que estavam na operação "Sufoco" para diminuir os índices de criminalidade. O local é conhecido como ponto de tráfico, viram uma pessoa dando dinheiro para o réu, este foi até uma caixa de papelão, pegou algo e entregou para aquela. Narrou que abordaram o réu, em poder dele havia dinheiro e o mesmo indicou que as drogas estavam em uma caixa de papelão, onde as apreenderam (divididas em porções). Disse que o local que o réu indicou era justamente o mesmo que este foi buscar algo e entregou para uma pessoa.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Leandro.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade (fls. 12 - 10 pedras de "crack", 5 porções de maconha e 26 invólucros de cocaína) e diversidade de drogas apreendidas ("crack", maconha e cocaína), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro, não sendo provada a sua procedência, as confissões informal e extrajudicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492).

No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

A negativa judicial do réu está isolada, posto que alegou que é usuário, mas nada provou como lhe incumbia nos termos do art 156 do CPP e sua versão foi desmentida pelos policiais no sentido de que o viram em atos típicos de tráfico, que foi apreendido dinheiro em seu poder, a confissão informal e extrajudicial e ainda apontou onde estavam as drogas, local que o viram mexendo e entregando para o usuário.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (10 pedras de "crack", 5 porções de maconha e 26 invólucros de cocaína) demonstram que se destinava ao tráfico. Ademais, sequer provou ser usuário.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 15/17) e laudo definitivo (fls. 78/80).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 54 - proc. 1500066-64.2020 - em R.A - fls. 56; fls. 56 - proc. 1465-08.2012 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 29.10.19 - fls. 123; fls. 56 - proc. 1537-95.2012 - em R.A - fls. 55).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

"Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos e 500 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Não é caso de aumento da pena-base diante da variedade de drogas, uma vez que no caso em tela a quantidade apreendida é pequena (nesta Comarca inferior a 100).

Compenso a reincidência e a confissão extrajudicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.ª Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito a decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art.

33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente por roubo

(fls. 54 – proc. 1500066-64.2020 e fls. 56 – proc. 1465-08.2012 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 29.10.19) e furto (fls. 56 – proc. 1537-95.2012), demonstrando que não foi um fato isolado em sua vida e que possui personalidade voltada para a prática de crimes, sendo que praticou este crime quando cumpria pena em regime aberto (fls. 54 – proc. 1500066-64.2020 – em R.A – fls. 56; fls. 56 – proc. 1537-95.2012 – em R.A – fls. 55), demonstrando que não teria

responsabilidade para cumprir regime menos gravoso. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 25.08.22 pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 24.12.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante) e por estar ainda em R.A quando praticou este crime não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO WALTER PALMA

REIS à pena de 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), inclusive conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, recomenda-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03) por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min.

Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 12 e 75/76) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União (art. 63 da Lei n.º 11343/06), providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto ao saco plástico apreendido (fls. 12), já periciado (fls. 81/82), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 63), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA